

Nulidades societarias

Régimen general y particularidades en materia societaria

Prof. Maximiliano Romei · Derecho Comercial ·
Universidad Nacional de Moreno

Las nulidades societarias

Punto de partida

Vítolo define la **nulidad** como una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico por una causa existente **al momento de su celebración**.

El Código Civil y Comercial estableció un nuevo régimen de nulidades, tanto respecto de su concepto como de su sistematización.

Pero trasladar directamente ese régimen al derecho societario presenta dificultades.

La sociedad no constituye simplemente un acto aislado: genera una organización, actividad, relaciones patrimoniales y vínculos con socios, acreedores y terceros.

Nulidad e inoponibilidad

El régimen general distingue dos formas de ineficacia.

Nulidad

El acto jurídico puede resultar ineficaz por encontrarse afectado por una causa de nulidad.

Inoponibilidad

El acto puede conservar su validez pero resultar ineficaz respecto de determinadas personas.

Vítolo parte del art. 382 CCyC: los actos jurídicos pueden ser ineficaces **en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.**

La distinción será relevante posteriormente al trasladar el problema al ámbito societario.

La nulidad puede invocarse de distintas maneras

El art. 383 CCyC permite que la nulidad:

- sea articulada **por vía de acción**;
- o sea opuesta **como excepción**.

En todos los casos debe sustanciarse.

Por lo tanto, la nulidad no queda limitada al supuesto en que una persona promueva una demanda cuyo objeto principal sea obtener la declaración de invalidez.

También puede hacerse valer defensivamente frente a una pretensión fundada en el acto afectado.

Conversión del acto nulo

El nuevo régimen incorpora la posibilidad de **conversión**. Un acto nulo puede convertirse en otro diferente y válido cuando:

- satisfaga los requisitos esenciales del nuevo acto;
- y el fin práctico perseguido por las partes permita suponer que ellas lo habrían querido si hubieran previsto la nulidad.

La conversión procura preservar, cuando resulte jurídicamente posible, la finalidad práctica perseguida. Vítolo vincula esta solución con el art. 384 CCyC.

El acto indirecto

El art. 385 CCyC contempla además el denominado **acto indirecto**.

Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado propio de los efectos de otro acto es válido cuando:

- no se otorgue para eludir una prohibición legal;
- ni para perjudicar a un tercero.

El nuevo régimen de ineficacia no se agota, por lo tanto, en una oposición simple entre acto válido y acto nulo.

Existen mecanismos destinados a determinar qué efectos jurídicos pueden conservarse.

Nulidad absoluta

Son de **nulidad absoluta** los actos que contravienen:

- el orden público;
- la moral;
- las buenas costumbres.

Vítole remite al art. 386 CCyC.

La nulidad absoluta puede ser declarada por el juez **aun sin petición de parte**, cuando resulte manifiesta al momento de dictar sentencia.

También puede ser alegada por el Ministerio Público y por cualquier interesado, con la excepción prevista respecto de quien invoque su propia torpeza para obtener un provecho.

Régimen de la nulidad absoluta

La nulidad absoluta presenta dos características particularmente relevantes:

No puede sanearse por confirmación.

El vicio que afecta al acto no puede eliminarse mediante una posterior manifestación de voluntad destinada a mantenerlo.

No puede sanearse por prescripción.

El transcurso del tiempo tampoco elimina esta nulidad. Estas características permiten diferenciarla claramente de la nulidad relativa.

Vítole remite al art. 387 CCyC.

Nulidad relativa

Son de **nulidad relativa** los actos a los cuales la ley impone esta sanción únicamente en protección del interés de determinadas personas.

A diferencia de la nulidad absoluta:

- sólo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio fue establecida;
- excepcionalmente puede invocarla la otra parte si es de buena fe y sufrió un perjuicio importante.

La nulidad relativa responde, por lo tanto, a la protección de un **interés particular** y no directamente a la tutela del orden público.

Saneamiento de la nulidad relativa

La nulidad relativa puede sanearse.

Vítolo menciona dos mecanismos:

- **confirmación del acto;**
- **prescripción de la acción.**

Existe además una limitación para quien obró con ausencia de capacidad de ejercicio: esa persona no puede alegar posteriormente la nulidad si actuó con **dolo**.

El contraste con la nulidad absoluta resulta claro:

absoluta → insanable

relativa → susceptible de saneamiento

Nulidad total y nulidad parcial

El Código distingue también según la extensión del defecto.

Nulidad total

Se extiende a todo el acto jurídico.

Nulidad parcial

Afecta únicamente una o varias de sus disposiciones.

La nulidad de una disposición no afecta las demás disposiciones válidas **si éstas son separables**.

Si no pueden separarse porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, corresponde declarar la **nulidad total**.

Integración en la nulidad parcial

La nulidad parcial no se limita a eliminar mecánicamente la cláusula inválida.

Cuando resulte necesario, el juez debe **integrar el acto**. Esa integración debe realizarse:

- de acuerdo con la naturaleza del acto;
- teniendo en cuenta los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes.

La solución del art. 389 CCyC procura, cuando sea posible, preservar el acto válido en lugar de destruirlo íntegramente.

¿Qué efectos produce la nulidad?

La nulidad pronunciada judicialmente vuelve las cosas al mismo estado en que se encontraban **antes del acto declarado nulo**.

Como consecuencia:

- las partes deben restituirse mutuamente aquello que hubieran recibido;
- las restituciones se rigen por las normas correspondientes a la buena o mala fe.

Vítolo remite al art. 390 CCyC.

Éste es el régimen general. Más adelante mostrará por qué su aplicación estricta genera dificultades especialmente importantes cuando el acto afectado es el **contrato de sociedad**.

El acto nulo puede producir consecuencias

Que un acto sea nulo no significa que carezca de toda consecuencia jurídica.

Vítoles recuerda que los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos propios de los actos válidos, pueden generar:

- las consecuencias jurídicas propias de los hechos en general;
- las reparaciones que correspondan.

La nulidad elimina los efectos propios que el ordenamiento hubiera reconocido al acto válido, pero no necesariamente borra **todo efecto jurídico derivado de lo ocurrido**.

Nulidad y derechos de terceros

El régimen también contempla la transmisión de derechos a terceros.

Los derechos reales o personales transmitidos sobre un inmueble o mueble registrable por quien adquirió mediante un acto nulo quedan, como principio, sin valor. Pueden ser reclamados directamente al tercero.

Sin embargo, Vítolo destaca la protección de los **subadquirentes de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso**, en los términos previstos por el art. 392 CCyC.

La nulidad debe, entonces, relacionarse también con la seguridad del tráfico jurídico.

Confirmación: sólo para la nulidad relativa

Vítolo enfatiza una diferencia fundamental:

la nulidad absoluta no puede sanearse mediante confirmación.

La confirmación sí puede operar respecto de la **nulidad relativa**.

Existe confirmación cuando la parte legitimada para articular la nulidad relativa:

- manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de considerar válido el acto;
- después de haber desaparecido la causa de nulidad.

La confirmación no requiere la conformidad de la otra parte.

Confirmación expresa y tácita

La confirmación puede asumir dos modalidades.

Confirmación expresa

El instrumento debe cumplir las formas exigidas para el acto que se pretende sanear y contener:

- mención precisa de la causa de nulidad;
- indicación de su desaparición;
- voluntad de confirmar el acto.

Confirmación tácita

Resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo, realizado con conocimiento de la causa de nulidad, o de otro acto que revele inequívocamente la voluntad de sanearlo.

Efectos de la confirmación

La confirmación de un acto entre vivos originariamente nulo tiene **efecto retroactivo** a la fecha de su celebración.

Cuando se trata de disposiciones de última voluntad, la confirmación opera desde la muerte del causante. Sin embargo, existe un límite fundamental:

la retroactividad de la confirmación no puede perjudicar los derechos de terceros de buena fe.

El saneamiento del acto no puede utilizarse para destruir situaciones jurídicas de terceros protegidas por el ordenamiento.

La otra cara de la ineficacia: inoponibilidad

Vítolo vuelve luego a la **inoponibilidad**.

El acto inoponible:

- no produce efectos respecto de terceros;
- salvo en los casos previstos por la ley.

La inoponibilidad puede hacerse valer **en cualquier momento**, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer:

- prescripción;
- caducidad.

Nulidad e inoponibilidad constituyen, de este modo, categorías distintas dentro del régimen general de ineficacia.

El problema específico del derecho societario

Vítolo advierte que en materia mercantil existen casos sometidos a un régimen especial.

La Ley 26.994 contempla **nulidades con efectos especiales**.

En estos supuestos, el acto puede:

- conservar sus efectos propios;
- imputar responsabilidad a quienes lo ejecutaron;
- responsabilizar a quienes consintieron o posibilitaron la situación.

Esto anticipa una idea central:

la nulidad societaria no puede comprenderse trasladando automáticamente las reglas generales de la nulidad civil.

¿Por qué la nulidad societaria es especial?

La nulidad del acto constitutivo de una sociedad constituye, según Vítolo —recordando a Halperin—, uno de los problemas más difíciles de la materia.

El régimen común fue construido pensando esencialmente en **negocios jurídicos de cambio**.

La sociedad presenta otra estructura:

- es un contrato plurilateral de organización;
- crea una organización;
- despliega una actividad;
- se relaciona con terceros;
- genera una persona jurídica diferenciada.

Por ello, las reglas tradicionales resultan muchas veces insuficientes o inaplicables.

La sociedad no es un acto instantáneo

La sociedad despliega **actividad**, no simplemente actos aislados.

En el tráfico mercantil se relaciona con:

- terceros;
- otros sujetos;
- socios;
- acreedores sociales;
- acreedores particulares de los socios.

Además, crea una **persona jurídica distinta** de quienes la integran.

Todo esto dificulta aplicar una solución concebida para un negocio de cambio en el cual la nulidad puede retrotraer los efectos al momento inmediatamente anterior a su celebración.

La nulidad societaria mira hacia el futuro

En el contrato de sociedad, el acto puede haber desplegado efectos durante un período considerable. Por ello, según Vítolo:

la nulidad opera con efectos hacia el futuro y nunca retroactivamente hacia el pasado.

La nulidad societaria no puede erradicar el pasado real, económico y jurídico producido por la actuación de la sociedad.

Esta característica constituye una diferencia fundamental respecto del régimen general de restitución propio de los actos jurídicos nulos.

Nulidad y responsabilidad

Vítolo agrega una advertencia conceptual importante.
En materia societaria no debe confundirse:

nulidad

con

responsabilidad.

La nulidad opera fundamentalmente respecto de la eficacia del vínculo o de la estructura societaria.

La responsabilidad constituye una consecuencia jurídica diferente y, en determinados supuestos societarios, puede adquirir una importancia incluso mayor que la propia sanción de nulidad.

El régimen societario combina mecanismos de ineficacia con mecanismos específicos de responsabilidad.

Nulidad del vínculo de un socio

Bajo la Ley 19.550 rige una regla particular.

La nulidad o anulación que afecte el vínculo de **alguno de los socios** no produce, como principio:

- la nulidad del contrato;
- la anulación del contrato;
- ni su resolución.

La afectación individual del vínculo de un socio no destruye automáticamente la sociedad.

El contrato y los vínculos correspondientes a los demás socios permanecen, en principio, indemnes.

Esta solución responde a la estructura plurilateral del contrato societario.

La excepción: prestación esencial

La regla anterior admite una excepción.

La nulidad del vínculo puede afectar al contrato cuando la participación o prestación del socio afectado deba considerarse **esencial**.

Vítolo propone ejemplos:

- sociedad destinada a explotar un fondo de comercio determinado, cuando el socio debía aportarlo;
- socio vinculado con un activo fundamental para la actividad;
- inmueble determinado;
- licencia de uso de una marca;
- franquicia;
- otros derechos intelectuales esenciales.

La clave es determinar si la sociedad puede cumplir su objeto sin esa prestación.

Sociedad unipersonal y vicio de la voluntad

La solución necesariamente cambia en una **sociedad unipersonal**.

Si existe un vicio en la declaración unilateral de voluntad del único constituyente, la consecuencia puede ser la **anulación de la sociedad nacida de esa declaración**.

Vítolo vincula esta solución con el art. 1800 CCyC.

La diferencia se explica fácilmente:

en una sociedad pluripersonal puede desaparecer un vínculo y subsistir los restantes;

en una sociedad unipersonal **no existen otros vínculos societarios que puedan conservarse**.

Nulidades estructurales: arts. 18, 19 y 20

Vítolo agrupa determinados supuestos de los arts. **18, 19 y 20 LGS** bajo la denominación de **nulidades estructurales**.

El régimen combina dos mecanismos:

Disolución y liquidación

La nulidad determina el cese y liquidación de la organización.

Responsabilidad

En ciertos supuestos se impone un régimen especialmente severo respecto de socios, administradores y quienes actuaron en la gestión social. Las consecuencias varían según el defecto estructural involucrado.

Sociedad con objeto ilícito — art. 18

Las sociedades que tengan un **objeto ilícito** son consideradas nulas de nulidad absoluta.

Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad.

Los socios, en cambio, no pueden alegar la existencia de la sociedad:

- entre sí;
- frente a terceros;
- para reclamar restitución de aportes;
- para reclamar división de ganancias;
- para reclamar contribución a las pérdidas.

Declarada la nulidad, se procede a la **liquidación**.

Objeto ilícito: liquidación y responsabilidad

La liquidación puede disponerse a pedido de parte o de oficio.

Realizado el activo y cancelado el pasivo social y los perjuicios causados, el remanente:

ingresa al patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva.

Además, los:

- socios;
- administradores;
- y quienes actúen como tales en la gestión social responden **ilimitada y solidariamente** por el pasivo social y los perjuicios causados.

Es el régimen del art. 18 LGS descripto por Vítolo.

Objeto lícito con actividad ilícita — art. 19

El segundo supuesto corresponde a sociedades que tienen:

objeto lícito + actividad ilícita.

Declarada la nulidad, debe procederse a:

- disolución;
- liquidación de la sociedad.

El régimen se aproxima al previsto para el objeto ilícito, pero presenta una diferencia importante:

los socios que acrediten su **buena fe** quedan excluidos:

- del destino especial del remanente liquidatorio;
- de la responsabilidad ilimitada y solidaria por el pasivo social y los perjuicios causados.

Objeto prohibido en razón del tipo — art. 20

El tercer supuesto corresponde a sociedades con un **objeto prohibido en razón del tipo societario**.

Vítolo menciona como ejemplo las actividades financieras o de seguros, que requieren determinados tipos específicos.

Estas sociedades son tratadas como las de objeto ilícito en cuanto a la nulidad.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental respecto de la liquidación:

se aplica el régimen ordinario de liquidación previsto en la Sección XIII de la LGS.

No se aplica, por lo tanto, el destino extraordinario del remanente previsto para el objeto ilícito.

Un problema de lenguaje legislativo

Vítolo critica expresamente el lenguaje utilizado por la Ley 19.550.

El legislador no fue suficientemente claro y utilizó distintas expresiones para situaciones que, desde el punto de vista jurídico, comparten una misma naturaleza. Por ejemplo:

- los arts. 18 y 20 hablan de sociedades **nulas de nulidad absoluta**;
- otras disposiciones utilizaron históricamente la expresión **simplemente nulas**.

Una lectura puramente literal podría conducir a conclusiones equivocadas sobre la posibilidad de confirmar o subsanar determinadas nulidades.

La posición de Vítolo sobre los arts. 18, 19 y 20

Vítolo rechaza que las diferencias terminológicas alteren la verdadera naturaleza de estos supuestos.

Las nulidades contempladas por los arts. **18, 19 y 20 LGS** son todas:

- **absolutas;**
- **inconfirmables;**
- **insubsanables.**

Las diferencias de lenguaje empleadas por el legislador constituyen, para el autor, una cuestión **enfática en el lenguaje**, pero sin verdadera trascendencia jurídica. El interés protegido impide su saneamiento.

Cuatro grupos de nulidades societarias

Vítolo advierte que la LGS no contiene un capítulo que sistematice conjuntamente todas las nulidades societarias.

Las disposiciones aparecen dispersas.

Sin perjuicio de ello, pueden reconocerse **cuatro grandes grupos**:

1. nulidades referidas al **vínculo societario**;
2. nulidades de **cláusulas contractuales o estatutarias**;
3. nulidades de **las sociedades**;
4. nulidad de **determinados actos societarios**.

Esta clasificación permite ordenar un régimen legal que carece de una sistematización unitaria.

¿Dónde aparecen esas nulidades?

Vítolo identifica, entre otras, las siguientes disposiciones:

Vínculo societario

Art. 16 LGS.

Cláusulas contractuales o estatutarias

Arts. 13, 69, 185, 194, 240, 245, 248, 287 y 322, entre otros.

Nulidades de las sociedades

Arts. 18, 19, 20, 27 y 29.

Nulidad de determinados actos societarios

Arts. 32, 38, 39, 199, 202, 227, 246, 271 y 337, entre otros.

La nulidad societaria constituye, por ello, un régimen **disperso dentro de la LGS.**

Vínculo societario y prestación esencial

Vítolo vuelve sobre la nulidad del vínculo para precisar la excepción de la **prestación esencial**.

Puede tratarse del socio que aporta un elemento sin el cual la sociedad no puede desarrollar adecuadamente su objeto:

- fondo de comercio;
- inmueble fundamental;
- licencia;
- marca;
- franquicia;
- derecho intelectual esencial.

En estos casos, la afectación del vínculo individual adquiere una dimensión estructural porque compromete la posibilidad misma de funcionamiento de la sociedad.

¿Qué puede ocurrir si la prestación era esencial?

Vítolo señala que pueden presentarse distintas consecuencias según la naturaleza del vicio.

Puede producirse:

- **nulidad del contrato**, si el vicio determina un supuesto de nulidad absoluta;
- **anulación**, cuando dependa de decisión judicial dictada a pedido del interesado;
- **resolución**, según la expresión utilizada por la ley.

Sin embargo, Vítolo formula una precisión importante respecto de esta última expresión.

No debe interpretarse necesariamente como extinción retroactiva de todo el contrato social.

La “resolución” y el principio de conservación

Para Vítolo, la palabra **resolución** utilizada por la ley no resulta técnicamente adecuada si se la entiende como extinción del contrato con efectos retroactivos.

Debe comprenderse como una:

resolución parcial del contrato respecto del socio afectado por el vínculo.

La solución se relaciona con el **principio de conservación de la empresa.**

La sociedad puede subsistir si:

- la prestación esencial del socio afectado puede ser reemplazada por la de un tercero que se incorpore;
- o la sociedad modifica su objeto o actividad para que esa prestación deje de resultar necesaria.

La eliminación de la nulidad por atipicidad

Vítolo cierra el fragmento analizando la **tipicidad**.

La tipicidad constituye uno de los parámetros utilizados por la Ley 19.550 para organizar el régimen societario.

A través de los tipos legales se procura que quienes pretenden constituir una sociedad puedan adecuarse organizativamente a estructuras conocidas.

Esto permite a los terceros conocer anticipadamente aspectos esenciales vinculados con:

- responsabilidad;
- representación;
- funcionamiento;
- relaciones entre la sociedad y quienes se vinculan con ella.

El antiguo régimen de atipicidad

Originariamente, el art. 17 LGS sancionaba con **nulidad** la constitución de una sociedad bajo tipos no autorizados por la ley.

La tipicidad funcionaba así como una exigencia cuya infracción comprometía directamente la validez de la sociedad.

La Ley 26.994 modificó profundamente este régimen. La atipicidad dejó de ser tratada como una causa de nulidad societaria.

Esta reforma altera de manera significativa las consecuencias derivadas de apartarse de los tipos previstos legalmente.

El régimen actual de las sociedades atípicas

Según el nuevo texto del art. 17, las sociedades previstas en el Capítulo II de la LGS —colectiva, capital e industria, comandita simple, comandita por acciones, sociedad anónima y SRL— no pueden:

- omitir requisitos esenciales **tipificantes**;
- incorporar elementos incompatibles con el tipo legal.

Pero la infracción ya **no determina la nulidad**.

La sociedad constituida:

- no produce los efectos propios del tipo;
- queda regida por la **Sección IV del Capítulo I**.

Atipicidad: la valoración de Vítoló

Vítoló considera acertada la modificación introducida por la Ley 26.994.

La nueva solución elimina la sanción de nulidad prevista por el antiguo art. 17.

Como consecuencia:

la sociedad es plenamente válida y eficaz.

Además:

las cláusulas del contrato social o estatuto son plenamente oponibles entre los socios, conforme al nuevo art. 22 LGS.

La reforma sustituye así la destrucción de la sociedad por un régimen jurídico específico aplicable a la organización que no se adecua al tipo.

Síntesis: régimen general y régimen societario

Régimen general

La nulidad puede ser absoluta o relativa, total o parcial. Puede producir restituciones y, cuando es relativa, admite confirmación.

Régimen societario

La aplicación de esas categorías exige adaptación porque la sociedad:

- crea una organización;
- desarrolla actividad;
- se relaciona con terceros;
- genera una persona jurídica;
- produce una realidad económica y jurídica que no puede simplemente borrarse.

Por ello, la nulidad societaria opera fundamentalmente **hacia el futuro**.

Síntesis de los supuestos estructurales

Art. 18 — objeto ilícito

Nulidad absoluta + liquidación + régimen especial del remanente + responsabilidad ilimitada y solidaria.

Art. 19 — objeto lícito con actividad ilícita

Disolución y liquidación + posibilidad de protección de los socios que acrediten buena fe.

Art. 20 — objeto prohibido en razón del tipo

Nulidad absoluta + liquidación conforme al régimen ordinario.

Para Vítolo, los tres supuestos contienen nulidades **absolutas, inconfirmables e insubsanables**.

Ideas centrales para retener

- 1.** La nulidad societaria no puede explicarse trasladando mecánicamente el régimen de los contratos de cambio.
- 2.** La nulidad del vínculo de un socio no destruye, como regla, todo el contrato social.
- 3.** La prestación esencial constituye una excepción relevante.
- 4.** Los arts. 18, 19 y 20 contienen nulidades estructurales con consecuencias diferentes.
- 5.** En materia societaria, la nulidad opera hacia el futuro y debe distinguirse de la responsabilidad.
- 6.** La Ley 26.994 eliminó la nulidad por atipicidad: la sociedad queda sometida al régimen de la Sección IV.

Speaker notes